

Política(s) e democracia: assimilação dos conflitos pela via judicial

Simone Braghin¹

Resumo

À luz dos conceitos de política, democracia, liberdade e igualdade em Hannah Arendt, Claude Léfort e Jacques Rancière, propõem-se nesse trabalho, uma reflexão acerca do Supremo Tribunal Federal (STF) como ator político capaz de assimilar questões antes colocadas à margem na ordem vigente. Para isso, apresento uma breve reflexão acerca desses conceitos e breve ilustração sobre o papel de atores (movimentos sociais, atores políticos institucionalizados, confederações sindicais, etc.) com voz no STF (como legitimados ativos) e ilustro alguns exemplos práticos de questões que essa Corte julgou e que se tratavam de questões polêmicas e de grande “relutância” social para serem incorporadas no regime estabelecido. As conclusões que se seguem são de cunho tão somente reflexivo e caminham para o entendimento de que a ordem vigente (*status quo*) se rearranja de modo a inserir demandas de minorias sem, contudo, assimilá-las “por completo” nessa ordem.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal, Movimentos Sociais, Política, Democracia, Igualdade.

Entendimentos: políticas e liberdade

Para Arendt (1987; 2011) a política não é regra – é exceção. É a liberdade fundamentada na capacidade de agir com outras pessoas para criar espaços compartilhados para resolução de conflitos – de diferenças. Em contraposição à ideia de tirania, a política é o *espaço* do diálogo e de construção de critérios de justiça e, por

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), membro do Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade (NEDJUS/PPGS) e bolsista CAPES. <simonebraghin@gmail.com> ; <<http://www.nedjus.ufscar.br>>.

consequência, do estabelecimento daquilo que é considerado como injustiça social. Na política, as discussões tangenciadas se referem aos problemas e conflitos sociais.

Desse modo, Arendt (Ibid.) afirma que a política se concretiza em qualquer espaço, ou seja, está nas relações sociais e não propriamente nas instituições políticas. Contudo, para que a política esteja garantida, dois elementos são necessários: a presença dessas instituições consolidadas, que balizam o entendimento sobre o velho e *regulem* a criação do novo e a vivência compartilhada da trajetória social e política.

Essas instituições não são necessariamente instituições políticas, conforme atribuímos aos poderes políticos institucionalizados e na figura de líderes eleitos ou não: são instituições de vínculo familiar, religioso, entre outros que permitam a partilha de valores similares. Vivência de trajetória social e política correspondem à memória de como se faz política por essas instituições, isto é, as regras, negociações, disciplinas, hierarquias, etc. estabelecidas em cada grupo.

Na modernidade, a política equivale a noção de *público* da filosofia grega e, o oposto grego – *privado* – corresponde à questão social. O social na modernidade é então uma esfera intermediária entre público e privado. É uma linha tênue que tangencia as questões públicas (políticas) e se discute questões do privado que são compartilhadas socialmente sem, contudo, mediar e introduzir esse privado no público, ou vice-versa.

O social é o espaço técnico em que é possível se pensar e discutir problemas práticos e nuances da vida – quer seja na relação entre o médico paciente, quer seja na relação entre vizinhos ou amigos, por exemplo. No espaço social ocorre a gestão desses problemas. Eles ou são administrados ou acobertados por um véu dissimulado de que não há problemas (questões) sociais. Nesse espaço encontramos o que a autora nomeia como *questão social* – uma força desumanizadora que impulsiona à revolução. São exemplos dessa questão social a pobreza e miséria, como atributos que rondam a vida privada e pública.

Sobre isso, repousa a distinção entre solidariedade e compaixão na obra de Arendt. A compaixão, como sentimento e noção compartilhada de que somos iguais (igualdade), concretiza-se no ato da caridade e noutras formas de auxílio *ao outro*, mascara assimetrias e a própria contradição de seu signo, dado que é esse código, enquanto sentimento que gera, segundo a autora, barbáries (formas de totalitarismo).

Por sua vez, o sentimento de solidariedade não mascara a possibilidade de que dificuldades e questões *sociais* são desiguais. A solidariedade é um sentimento de

partilha. Ele torna possível o *fazer* política e a conciliação e criação de critérios de justiça entre os desiguais.

Esses critérios de justiça são formas de proteção jurídicas que garantem a condição elementar de pessoas com direitos a ter direitos sem quaisquer critérios de distinção entre grupos ou indivíduos. Em contraposição a isso, a questão social evidencia, ainda na sociedade moderna, a presença de pessoas excluídas dessa condição de pessoa jurídica. Esse é o caso dos *pareas*: pessoas que, por motivos de crenças religiosas ou diferenças de diversas ordens (sexual, gênero, raça, etnia, etc.) são colocados “à margem” do ordenamento jurídico e da condição de portadores de direitos de igualdade.

Em proximidade com pensamento arendtiano, Claude Léfort (1991) discorre sobre a democracia e liberdade. Para ele, é importante entender a democracia e a liberdade, sobretudo por uma perspectiva histórica. Das grandes monarquias, aos regimes totalitários, a noção de poder é central para entender o argumento desse autor.

A forma de legitimação do regime, isto é, o poder atribuído a um governante, é o que garante o *status quo* e permite colocar o povo na condição de servo. A noção de servidão é então o oposto à liberdade. Ela é a expressa na ação – pacífica ou manifesta – de creditar como *legítimo* o poder daquele que o detém, abrindo mão da liberdade e colocando-se na condição de servo – obedecendo ao rei, ao ditador...

Léfort (Id.) afirma que os regimes democráticos invertem essa lógica. Neles a liberdade torna-se um valor concretizado e o poder se torna um *lugar vazio*, isto é, ele é exercido em nome do povo por pessoas – do povo – escolhidas para representar e exercer o poder visível: aquele institucionalizado e burocratizado. Assim, o poder não é mais atribuído como algo particular de um indivíduo eleito “por deus” ou de grupo legitimado “pela força”, mas, ao contrário, é atribuído ao próprio povo.

Esse “ente” que se refunda vira então dono de si. Esse povo institucionaliza o jogo político que, assim como em Arendt (1987; 2011), representa a resolução de conflitos sociais.

Ao passo que a política é o campo de ajustes dos conflitos em Arendt (Id.) e Léfort (Ibid.), o que difere nesses autores é onde “mora” a política. Como já descrito aqui, para Arendt a política, isto é, a resolução dos conflitos, ocorre fora das instituições políticas. Léfort afirma que a resolução dos conflitos é institucionalizada e que cabe então ao povo eleger e referendar a continuidade daqueles que exercem o poder em seu

nome, como, por exemplo, na máxima da Constituição brasileira de 1988, onde “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”².

Ao passo que a liberdade é a chave para se entender a democracia em Léfort (Ibd.), a problemática que se faz está fundada na noção de servidão, que segundo o autor, é possível existir em um sistema democrático. Ela, par oposto da liberdade, representa a luta pela ordem que é estabelecida na democracia. Ora, uma vez que a sociedade é constituída de grupos heterogêneos, os conflitos não são de todo resolvidos.

Remetendo ao estado de natureza de Hobbes (1974), no estado democrático de direito, “a guerra de todos contra todos”, transforma-se na “guerra de *todos* contra *alguns*”, ou seja, de maiorias – que ajustam e reajustam os poderes e que os exercem – contra tudo aquilo (ou todos aqueles) que lutam e se colocam contrários a essa ordem estabelecida: gerando o conflito (política) e a insegurança do regime político institucionalizado.

Ao mesmo passo que essa insegurança é motor do conflito (da política), ela também é o sentimento que permite a renúncia das liberdades desses indivíduos. Esse estado de servidão se assemelha então à definição rousseauiana de alienação, onde, “alienar é dar ou vender. Ora, um homem, que se faz escravo de um outro, não se dá; quando muito, vende-se pela subsistência. Mas um povo, por que se venderia? [...] Dirão que um déspota assegura aos súditos a tranquilidade civil.” (1999:61).

A obra de Léfort (op. cit.) corrobora então para refletirmos acerca de que, em uma democracia, vícios privados costumeiramente invadem a esfera política institucionalizada; que grupos ou pessoas que por vezes “vendem promessas” de manutenção da ordem, ao serem ouvidos e assimilados como “líderes”, podem tentar usurpar do poder “real”, transformando o soberano povo em vassalo. O que garante então a manutenção da ordem democrática?

Na contramão de Arendt (1987; 2011) e Léfort (1991), onde a política é o local de construção do consenso, Jacques Rancière (1996; 2005) a vê como o rompimento da ordem: ela é o próprio conflito. Esse conflito se torna possível devido à noção de igualdade que é compartilhada socialmente. Pobres, ricos, minorias e maiorias sociais compartilham do ideal de igualdade jurídica. Um ideal francês revolucionário que, nos

² Art. 1 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 11 ago 2015.

dias correntes, torna factível à grupos subalternizados e estigmatizados a luta pela concretização de seus direitos.

Essa ideia de igualdade não é nada mais do que uma noção filosófica que estabelece na vida das pessoas, que dele compartilham, um ponto de partida para que se concretize a luta pela realização plena dessa igualdade. Por isso, e como nomeia Rancière (1996), essa igualdade é vazia. Ela ocorre no plano teórico-filosófico. É um valor, um *querer*, um ideal inatingível. A tomada de consciência da noção de sujeito portador de identidade transforma grupos em demandantes dessa igualdade (*vazia*) vendida nos livros e disseminada como um “valor natural” e jurídico. No entanto, é esse *tornar-se igual* o que possibilita a política.

O conflito da política só é possível, para esse autor, quando o dissenso ocorre entre questões que são comuns entre os desiguais, isto é, assuntos que são semanticamente compartilhados. Quando os desprovidos (pobres: como figura antagônica aos ricos – providos de títulos, posses, prestígio, etc.) questionam a ordem estabelecida, o fenômeno da política (conflito) compromete a ordem estabelecida. Ocorre então que essa política não gera uma revolução abrupta na ordem – ela é assimilada, tornando-se o fenômeno da *polícia* – que significa para esse autor o reordenamento da ordem vigente.

Em suma, a ordem estabelecida coopta os dissidentes – tornando-os parte dessa maioria –, de forma a incluí-los na ordem com algumas distinções: os incluem, mas sem a retirada dos estigmas e “especificidades” que essas pessoas/grupos possam ter. Por exemplo, podemos nos lembrar da assimilação das mulheres nas urnas no Brasil.

Apenas em 1946 as mulheres foram totalmente incluídas como eleitoras: assunto que era discutido desde a Constituição de 1824³. Contudo, ainda assim e até o ano de 2005, mulheres eram separadas em dois grupos (honestas e desonestas), protegendo legalmente as “honestas” de “crimes contra os costumes”⁴, e não definindo o entendimento jurídico – e nem protegendo – as ditas como “desonestas”, evidenciando então que o que estava em regime de proteção jurídica não era a pessoa da mulher (de qualquer mulher) e sim a sociedade: seus valores e costumes.

³ Cf. <<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Abril/serie-inclusao-a-conquista-do-voto-feminino-no-brasil>>; <<http://migre.me/r9HCF>>. Acesso em: 11 ago 2015.

⁴ Cf. <<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/484154-FAZ-DEZ-ANOS-QUE-EXPRESSAO-MULHER-HONESTA-FOI-RETIRADA-DO-CODIGO-PENAL.html>>. Acesso em 12 dez 2015.

Até hoje, mulheres lutam pelo direito de poder decidir sobre seus corpos – sobre o aborto e desejos de sexualidade –, pela isonomia da faixa salarial recebida por homens na mesma posição de ocupação ou profissão, etc. Questões como essas, são fatos que marcam a ampliação da noção de poder para grupos não “notáveis”⁵. A assimilação desses grupos de *páreas*, no entanto, é feita a conta-gotas e conforme o samba político e social.

Por sua vez, esses notáveis donos do poder e ditadores da ordem vigente, revoltam-se contra a democracia, pois ela, enquanto poder que não é exclusivo da maioria, é tida – por essas majorias – como uma democracia impura, em comparação com a democracia dos antigos (grega).

Gera-se com isso um impasse no entendimento do que *é* e do que *deve ser* a democracia. A partir disso, segundo Rancière (op. cito), esses “notáveis” providos de seus privilégios no regime democrático, autoinstituídos por suas cercas fincadas na terra⁶, se colocam contrários à democracia, adotando posturas pró-regimes totalitários, por exemplo. Ao que parece, quer queira quer não, esse processo é um fruto do constante desentendimento entre os grupos – fator de disputada mais que esperado em uma democracia.

STF, mudanças a partir da luta jurídica por direitos e os legitimados ativos

O Supremo Tribunal Federal (STF) é a Corte constitucional brasileira e detém o papel de zelar pelo cumprimento das normas constitucionais em todo território nacional. Contudo, seu poder exercido sobre matéria legislativa é limitado à quando lhe acionam – é um poder de ação exclusivamente reativo. Sem o devido questionamento por atores sociais e políticos com a prerrogativa de o acionarem, indagando sobre questões que não são ou não resolvidas pela política tradicional, essa Corte não pode interferir nas normas produzidas ou pelo descumprimento das mesmas. E essa prerrogativa se limita a própria ordem.

⁵ Faço alusão a Assembleia dos Notáveis (*Assemblée des Notables*): conselho consultivo francês composto pela nobreza francesa e clero. Seus membros, eleitos pelo rei, eram responsáveis por aconselhá-lo e auxiliar na manutenção da ordem.

⁶ Faço alusão à Rousseau: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer ‘isto é meu’ e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. (1999:87).

Os atores autorizados a acioná-lo são, segundo artigo 103 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional⁷.

Imagina-se, então, que muitas das demandas sociais dos desprovidos ficam “à deriva” aguardando serem assimiladas, quer pela política institucionalizada, quer pela via jurídica, uma vez que não são todos os atores sociais que possuem voz ativa ou que se fazem representados por esses legitimados. Não são todas ou qualquer organização social de representatividade de classe trabalhista ou de movimentos sociais de luta contra desigualdades das minorias – sejam elas étnicas, raciais, de gênero, homossexuais, etc. – que são, a todo e qualquer custo, representados por atores legitimados ativos.

Na democracia, o último mecanismo de controle de maiorias tirânicas (representadas ou exercendo seu poder diretamente) é a magistratura livre de interferências. A magistratura, enquanto poder instituído pela democracia vigente, tem a tarefa de conservar o *status quo* frente a mudanças bruscas e não calculadas que ora eram (e ainda o são) demandadas pelo povo aos seus representantes políticos eleitos (Tocqueville 1962). Desse modo, a Corte responsável pelo controle das leis detém a responsabilidade de frear os desejos de maiorias representativas quando invadem liberdades e direitos individuais ou coletivos (Arantes 2013).

Ocorre que, com o ideal de igualdade disseminado e instaurados conflitos entre grupos providos e desprovidos, a ordem vigente fica comprometida e, por isso, necessita ser rearranjada (Rancière 1996; 2005). Rosenberg (1993) afirma que mudanças sociais ocasionadas pelo litígio frequentemente ocorrem quando poderes governamentais falham em agir ou fazem oposição ao tema, em questão, demandado socialmente.

O aumento da consciência sobre os direitos na cultura popular é, Segundo Epp (1998), um elemento importante para a transformação desses mesmos direitos. Porém, o que de fato possibilita transformações nessa esfera são as pressões promovidas de modo deliberado e estratégico por atores sociais vinculados à movimentos sociais e grupos de

⁷ Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 24 set 2014.

advogados e servidores públicos do direito – como defensores públicos, promotores, etc. Pela via judicial, podem ocorrer mudanças significativas na estrutura e ordem social vigente, mas, há limites a elas. E esses limites podem ocorrer por diversos fatores: quer pelo não cumprimento das decisões pelos poderes políticos, reordenamento institucional, não obediência das normas pela parcela notável da população, etc.

Contudo, o Judiciário federal impacta diretamente nas políticas públicas formuladas pelo governo federal e na ordem vigente, ao permitir – mesmo que de modo reduzido – que atores minoritários tenham suas demandas vocalizadas e incorporadas.

Taylor (2007) afirma que há evidências sugerindo que o Judiciário é acionado com base na Constituição ou legislação ordinal para deliberar sobre políticas públicas contenciosas e, além disso, ele é utilizado por atores políticos como via de contestação (*venue seeking*) de políticas públicas implementadas por setores/grupos políticos majoritários, quando esses não conseguem fazer-se vocalizar nas arenas de debates públicos representativos.

Essa possibilidade de ação pela via judicial, ainda mais quando se tratando de ausência de representatividade política, corrobora para a impulsão da gestão de conflitos de política (ou própria política, nos termos de Rancière), tanto de modo a assimilar sem propriamente incluir, como também enquanto uma ferramenta de manutenção dos ideais de igualdade e das formas de luta política desses movimentos minoritários.

Assimilações jurídicas

Em 2008, o STF realizou dois julgamentos que tiveram grande repercussão midiática. O primeiro instituía o uso de normas para o uso de algemas; o segundo considerava as pesquisas com células-tronco legítimas constitucionalmente. A decisão que regulou o uso das algemas foi tomada após um pedreiro ter permanecido algemado durante todo o processo de julgamento que enfrentou.

O STF anulou esse julgamento e, por considerar a prática abusiva e também como uma *tortura*, estabeleceu a súmula vinculante que restringe o uso das algemas em casos particulares, onde possa haver riscos (de fuga, resistência à prisão ou locomoção

do preso, etc.)⁸. A aplicação da súmula vinculante estabeleceu um padrão de julgamento e o cumprimento constitucional de preceitos garantidores de direitos civis.

A consulta e consequente decisão dessa Corte permitindo o uso de células-tronco embrionárias para pesquisas (que visam encontrar a cura de mais de 7 mil doenças degenerativas) obteve grande participação popular, em especial, de um lado, por grupos religiosos, e de outro, por pesquisadores e pacientes com diversas doenças degenerativas. A grande polêmica que norteou esse debate foi entender aonde começa (e termina) a vida, porque o que era alegado por aqueles contrários à prática – representados, em grande maioria, por religiosos – era que a vida, segundo preceitos bíblicos e cristãos, começa com a fecundação.

Já alguns dos cientistas, defendiam que se a morte é declarada quando se extingue a neurotransmissão, a vida não é possível antes de sua formação – que ocorre após a 23ª semana de gestação. Nessa discussão em si não houve argumento vencedor ou perdedor.

O que foi central para a decisão do STF foi a argumentação realizada pela geneticista Mayana Zatz que fez uma (eficaz) provocação à Corte: "O que é eticamente mais correto: preservar um embrião congelado, mesmo sabendo que a probabilidade de ele gerar um ser humano é praticamente zero, ou doá-lo para pesquisas que poderão resultar em futuros tratamentos?"⁹

Essa decisão do STF favorável ao uso contrariou muitos grupos “notáveis”. A decisão em si, pode ser resumida pelo argumento da juíza (e cristã fervorosa)¹⁰ Ellen Gracie:

Nem se lhe pode opor a garantia da dignidade da pessoa humana, nem a garantia da inviolabilidade da vida, pois, segundo acredito, o pré-embrião não acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como pessoa.” Ela assinalou que a ordem jurídica nacional atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. “Por outro lado, o pré-embrião também não se enquadra na condição de nascituro, pois a este, a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer, o que não acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte¹¹.

⁸ Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>>. Acesso: 11 ago 2015.

⁹ Cf. < http://agencia.fapesp.br/quando_comeca_a_vida/7038/>. Acesso em 11 ago 2015.

¹⁰ Cf. Entrevista de Carlos Graieb à Ellen Gracie Northfleet, intitulada “Fé na Justiça” – Veja (Acervo Digital), Edição nº 2051 de 12 de março de 2008, p. 11- 15. Acesso em: 15 ago 2015.

¹¹ Cf. < <http://stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=89917>>. Acesso em: 11 ago 2015.

Em 2011 a Corte reconheceu como constitucional a união estável entre pessoas do mesmo sexo¹². Sua decisão assimilou na ordem estabelecida mais de 60 mil pessoas que se declararam em uma união estável homossexual ao IBGE¹³. Com isso, a Corte decidiu pela exclusão de qualquer significado no art. 1.723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, de modo que qualquer forma de discriminação desse tipo de união é uma colisão com o inciso IV do art. 3 da CF/88, que veda quaisquer formas de discriminação (por raça, cor, etc.).

Outro passo nesse sentido de *assimilação* foi a decisão da Corte no Recurso Extraordinário (RE) nº 656.298, que, em caráter de repercussão geral, atribuiu o reconhecimento jurídico das uniões estáveis concomitantes à relações homoafetivas e heteroafetivas, igualando-as juridicamente no sentido do rateio da pensão por morte¹⁴; e a decisão do RE nº 646.721 que garante o direito a herança em união homoafetiva.

Ao defender a repercussão geral da matéria, o recorrente sustenta que a questão tem implicações sociais, políticas, econômicas e jurídicas que ultrapassam o interesse subjetivo das partes envolvidas. Afirmar, ainda, a necessidade de se tratar os casais homossexuais sem qualquer distinção ou discriminação, e ressaltar a possibilidade de a decisão sobre o caso se refletir em “incontável número de processos no Judiciário nacional”¹⁵.

Contudo, essas decisões (com caráter de repercussão geral) não garantiram a plenitude do direito desse grupo recém-assimilado (nesse viés) à ordem. Precisou-se que, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – órgão corregedor do sistema jurídico no país – divulga-se uma resolução “obrigando” cartórios a respeitarem a *ordem reordenada*¹⁶.

“A Resolução veio em uma hora importante. Não havia ainda no âmbito das corregedorias dos tribunais de Justiça uniformidade de interpretação e de entendimento sobre a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da conversão da união estável entre

¹² Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931&caixaBusca=N> >. Acesso em: 15 ago 2015.

¹³ Cf. < <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm1605201113.htm> >. Acesso 12 ago 2015.

¹⁴ Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=202820&caixaBusca=N> >. Acesso em: 15 ago 2015.

¹⁵ Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=194359&caixaBusca=N> >. Acesso em: 15 ago 2015.

¹⁶ Cf. < http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf >. Acesso em: 12 ago 2015.

casais homoafetivos em casamento”, disse o conselheiro Guilherme Calmon. “Alguns estados reconheciam, outros não. Como explicar essa disparidade de tratamento? A Resolução consolida e unifica essa interpretação de forma nacional e sem possibilidade de recursos”, ressaltou. (Guilherme Calmon)¹⁷.

Após isso, para a “completa” assimilação desse segmento na ordem, restava a adequação da adoção de crianças por esses casais – o que ocorre em julgamento proferido em 05 de março de 2015. A partir de então, a noção de “família” é estendida à casais do mesmo sexo – tanto em regime de união estável, quanto em regime de casamento –, conforme decisão monocrática da relatora do RE 846.102, a ministra Carmén Lúcia:

A Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. [...] Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indistigavelmente preconceituoso ou homofóbico. [...] A isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família¹⁸.

Essa contínua e segmentada luta das pessoas homossexuais trás à luz a noção de assimilação e contínuos ajustes na ordem (polícia) e também a ideia de que, por mais assimilado que esse grupo esteja (assim como diversos outros que poderíamos pensar), as diferenciações e estigmas sociais que os seguem não deixarão de existir quer haja leis e normas que os “protejam”. Como a própria ilustração do caso jurídico nos mostra, ocorreram barreiras institucionais, por parte de cartórios e juízes, para a implementação das decisões vindas de cima (STF).

¹⁷ < <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalDestaques&idConteudo=238515>>. Acesso em: 12 ago 2015.

¹⁸ Cf. Recurso Extraordinário nº 846102 < <http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24.SCLA.+E+846102.NUME.%29+NAO+S.PRES.&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/psgqzt8>>. Acesso em 12 ago 2015.

Não podemos deixar de ter em mente que se há nessas e outras instituições descumprimentos das normas reordenadas, é porque essas instituições não são neutras e ainda mais, elas são preenchidas pelo aparato burocrático – o que significa a inserção de pessoas que, além de exercerem suas funções, como servidores públicos, são dotadas de sentimentos, desejos, preconceitos, opiniões, valores...

Isso tudo tende a influenciar a manutenção da ordem e seu policiamento (no sentido rancièreniano de reordenamento da ordem vigente). Além disso, a assimilação das demandas dos desprovidos não garante o fim das formas de discriminação que ocorrem tanto de modo institucionalizado, como no cotidiano das ruas.

Em 2015, um jovem negro tem 2,5 vezes mais chance de ser morto que um jovem branco, segundo relatório da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República¹⁹. A partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), o Mapa da Violência de 2015 aponta que, em 2013, diariamente 7 vítimas de feminicídio, ou seja, 50,3% de um total de 4.762 homicídios nesse ano, tiveram como autores de suas mortes algum familiar²⁰.

Em critério ilustrativo – e na ausência de dados mais recentes e oficiais –, os dados do 2º Relatório Sobre Violência Homofóbica 2012, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), apontam um total de 9.982 denúncias relativas a casos de crimes motivados por homofobia, sendo que esse montante não representa necessariamente apenas uma agressão por denúncia²¹. Dados do Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais no Brasil de 2014, do Grupo Gay da Bahia (GGB) apontam que 326 pessoas foram mortas em crimes de ódio e aversão à homossexuais. Aproximadamente, um assassinato a cada 27 horas²².

Outros temas que tiveram grande repercussão e rearranjaram a ordem social estabelecida, incorporando alguns desprovidos, foi o tema do aborto de anencéfalos²³ e

¹⁹ Cf. <<http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/jovem-negro-tem-25-vezes-mais-chance-de-ser-morto-diz-relatorio.html>>. Acesso em 28 jan. 2016.

²⁰ Cf. <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em 30 jan. 2016.

²¹ Cf. <<http://www.sdh.gov.br/noticias/2013/junho/numero-de-denuncias-de-violencia-homofobica-cresceu-166-em-2012-diz-relatorio>>. Acesso em 28 jan. 2016.

²² Cf. <<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relate3b3rio-2014s.pdf>>. Acesso em 28 jan. 2016.

²³ Cf. <<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-decisao-historica-stf-decide-que-aborto-de-feto-anencefalo-nao-e-crime-imp-,860498>>. Acesso em: 12 ago 2015.

o debate sobre a constitucionalidade das cotas raciais²⁴. Ambos, de modo progressista, assimilaram demandas de minorias de gênero e minorias raciais, respectivamente.

O primeiro caso descriminaliza mulheres e médicos que abortam fetos em condições de anencefalia²⁵. Segundo o ministro Ayres Britto, a obrigatoriedade da continuação da gravidez de fetos nesta condição é correspondente a formas de tortura.

O tema das cotas raciais em universidades, em particular, o caso da UnB, foi fruto no STF de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 186) ajuizada pelo partido dos Democratas. Ação distribuída em 20 de julho de 2009, e teve seu fim no julgamento realizado em abril de 2012, quando a Corte declarou improcedente a arguição²⁶. A Corte, acompanhando o voto do ministro relator, entendeu que a política pública de ação afirmativa da UnB não era desproporcional e, portanto, era compatível com os preceitos constitucionais:

De acordo com o artigo 5º, caput, da Constituição, "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Com essa expressão o legislador constituinte originário acolheu a ideia – que vem da tradição liberal, especialmente da Declaração do Homem e do Cidadão francesa de 1789 – de que ao Estado não é dado fazer qualquer distinção entre aqueles que se encontram sob seu abrigo.

[...]

A toda evidência, não se ateu ele, simplesmente, a proclamar o princípio da isonomia no plano formal, mas buscou emprestar a máxima concreção a esse importante postulado, de maneira a assegurar a igualdade material ou substancial a todos [...] levando em consideração – é claro – a diferença que os distingue por razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais

[...]

A adoção de tais políticas, que levam à superação de uma perspectiva meramente formal do princípio da isonomia, integra o próprio cerne do conceito de democracia.

[...]

[A justiça distributiva] permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, mediante uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las, realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da coletividade como um todo.

[...]

Ora, as políticas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País [...] [devem] ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado

²⁴ Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042>>. Acesso em: 12 ago 2015.

²⁵ Ausência total ou parcial do encéfalo.

²⁶ Cf. < <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042>>. Acesso em: 08 ago 2015.

brasileiro, desconsiderando-se os interesses contingentes e efêmeros que envolvem o debate.

[...]

De fato, critérios ditos objetivos de seleção, empregados de forma linear em sociedades tradicionalmente marcadas por desigualdades interpessoais profundas, como é a nossa, acabam por consolidar ou, até mesmo, acirrar as distorções existentes.

Os principais espaços de poder político e social mantêm-se, então, inacessíveis aos grupos marginalizados, ensejando a reprodução e perpetuação de uma mesma elite dirigente. Essa situação afigura-se ainda mais grave quando tal concentração de privilégios afeta a distribuição de recursos públicos.

Como é evidente, toda a seleção, em qualquer que seja a atividade humana, baseia-se em algum tipo de discriminação. A legitimidade dos critérios empregados, todavia, guarda estreita correspondência com os objetivos sociais que se busca atingir com eles. (Ministro Relator Ricardo Lewandowski).²⁷

Essa decisão do ministro relator, Ricardo Lewandowski, reflete bem as disputas incutidas no ambiente social e político brasileiro por desprovidos (visando o acesso, inclusão, e demais formas de justiça social) e a luta pela manutenção de bens, serviços ou privilégios dos grupos inseridos na ordem vigente – que são representados pelas “notáveis” elites políticas, econômicas e sociais. Além disso, essa decisão ilustra bem como o direito, enquanto esfera de poder institucional mantenedor da ordem vigente, também opera na condição de rearranjá-la.

Finalizo essa seção trazendo dois pontos de pauta dessa Corte que ainda não tiveram uma conclusão: a discussão sobre terras quilombolas (em trâmite há, aproximadamente, 12 anos) e a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio (em trâmite há, aproximadamente, 4 anos).

No primeiro caso, o que está em discussão é o direito constitucional da terra ocupada como propriedade dos grupos étnicos²⁸ – consequente demarcação desse território via titulação legal –; a proibição de pesquisas e atividades de mineração nas terras quilombolas, assim como o cancelamento das autorizações de minerações que acontecem nos dias atuais²⁹.

Após votação sobre essa matéria no STF ter resultados divergentes, a decisão não foi tomada, postergando quaisquer ações que possam estabelecer a ordem jurídica

²⁷ Cf. < <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693> >. Acesso em: 08 set 2015.

²⁸ Art. 68 da Constituição de 1988. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 12 ago 2015.

²⁹ Cf. < <http://cpisp.org.br/email/campanha02out13/index.html> >. Acesso em: 15 nov. 2015.

que permita a esses grupos estarem, de certo modo, melhor assimilados, ou que indiretamente lhes retirem os direitos já estabelecidos constitucionalmente. O cenário atual de indecisão coloca a condição desses quilombolas (que é datada, com a CF/88) em estado de limbo entre a assimilação em letra morta e a concreta efetividade.

Já a questão das drogas é pauta de conflitos de opiniões entre grupos de usuários e não usuários “conservadores”³⁰. A grande questão que baliza o debate em prol ao uso das drogas é o preceito constitucional estabelecido no item X do artigo 5º da CF/88, que estabelece que a intimidade e vida privada é um direito que deve ser garantido pelo Estado.

Entretanto, nesse mesmo artigo, o item XVII estabelece que “é plena a liberdade para fins lícitos”. A descriminalização das drogas para consumo próprio permitirá a associação para o consumo compartilhado; entretanto, quem fará a venda? Quem a regulará a produção doméstica e comercial? Essa pauta representa limites entre práticas individuais, regulação de mercado e duas discussões de grande importância no cenário global: o combate ao tráfico associado ao crime organizado e a saúde pública.

Considerações

Os exemplos acima buscaram trazer elementos práticos de como a política institucionalizada³¹, os critérios de justiça³² e formas de conflitos nas práticas sociais requerem nova ordem e reorganizam essa ordem estabelecida³³, por meio de processos de dissensos. Procurei demonstrar como essas mudanças na ordem democrática são constantes e sutis em momentos pontuais, mas que, ao longo de toda uma trajetória democrática, geram impactos e modificações em sua própria noção *de democracia* e consequente arranjo institucionalizado, de forma a incluir desprovidos nas fileiras das majorias, mesmo que ainda com estigmas que os diferenciarão.

Não obstante, não podemos negligenciar nesses exemplos a presença dos grupos sociais que lutaram arduamente (e muitas vezes com sangue) para obter alguns desses

³⁰ A condição de não usuários com o adjetivo “conservadores” é colocada, considerando que existem grupos de não usuários que são favoráveis à liberação e porte para consumo próprio e/ou legalização de uma ou mais formas de uso e produção de drogas.

³¹ Arendt, op. cit.; Léfort, op. cit.

³² Arendt op. cit.

³³ Rancière (op. cit.).

direitos. Para muitos, o grande desafio é e mantê-los na letra do direito e, no cotidiano, fazê-los cumpridos. A proposta deste artigo foi a de refletirmos sobre esse processo de assimilação dessas e outras demandas que em breve serão julgadas pelo STF, tendo como pano de fundo que elas foram (e ainda o são) encabeçadas por movimentos sociais e grupos não organizados que antecederam essas decisões judiciais e que pouco tem voz ativa nessa arena decisória.

Esses conflitos e posicionamentos *pró* ou *contra* avanços na agenda de direitos, de reconhecimento das demandas dos desprovidos (de igualdade de renda, acesso(s) à justiça e cidadania) é, em grande medida, motor de mais desentendimentos e lutas políticas não institucionalizadas. Em geral, é dinâmica do regime democrático. Como bem se sabe o reconhecimento legal da igualdade entre os diferentes e reordenamento da ordem de modo inclusivo não garante que os direitos desses segmentos sociais sejam totalmente respeitados na prática social, porém, já há um avanço.

Referências bibliográficas

ARANTES, R. B. Judiciário: entre a Justiça e a Política. Disponível em: <http://www.forumjustica.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ARANTES_EntreaJusticaPolitica.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2013.

ARENDT, H. **Homens em tempos sombrios**. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

_____. **Da Revolução**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

EPP, Charles. R. **A revolução dos direitos**: advogados, ativistas e Supremas Cortes em perspectiva comparada. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

LÉFORT, C. **Pensando o político**: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

HOBBS, T. **O Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil**. São Paulo: Abril Cultural, 1974.

RANCIÈRE, J. **La haine de la démocratie**. Paris: La Fabrique Éditions, 2005.

_____. **O desentendimento**. São Paulo: Editora 34, 1996.

ROSENBERG, Gerald Morris. **The Hollow Hope**: Can Courts bring social change? Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

ROUSSEAU, J. **Do contrato social**. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

_____. **Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens**. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

TOCQUEVILLE, A. **A democracia na América**. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1962.